

1506101-28.2021.8.26.0362

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PAULO ROGERIO MALVEZZI

Comarca: Mogi-Guaçu

Foro: Foro de Mogi Guaçu

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/03/2022

... necessidade e que já havia praticado tráfico quando ainda menor de dezoito anos. No entanto, em razão da dificuldade financeira, decidiu voltar ao tráfico de drogas. Disse que recebia entre R\$ 60,00 a R\$ 80,00 e que estava praticando tráfico de drogas há dez dias no local.

Com efeito, o depoimento prestado pelos guardas municipais é digno de toda credibilidade, já ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Guaçu

Foro de Mogi Guaçu

Vara Criminal

Rua José Colombo, 45, Mogi Guacu - SP - cep 13840-065

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1506101-28.2021.8.26.0362 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506101-28.2021.8.26.0362

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

LUÍS HENRIQUE FERRAZ DE ARAUJO e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

Luís Henrique Ferraz de Araújo foi denunciado e está sendo processado, porque no dia 14 de dezembro de 2021, por volta das 15h30min, na Rua dos Girassóis, em frente ao numeral 130, Ypê Pinheiros, neste Município e Comarca de Mogi Guaçu, nas imediações de uma praça pública, da CEI Clotilde Miachon Bueno, da UBS Dr. Eitel Falsetti, do Centro Educacional Ernest Mahle, de um campo de futebol e de uma área verde com bancos, vendeu e entregou 07 (sete) sete microtubos contendo cocaína, pesando 9 gramas, a Rafael Rodrigues de Oliveira, bem como trazia consigo, para fins de tráfico e entrega a terceiros, outros 08 (oito) microtubos contendo cocaína, pesando 10 gramas, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, e o fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado apresentou defesa prévia (fls. 78/82) e a denúncia foi recebida pela decisão de fls. 99/101.

Houve citação (fls. 153).

A representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal e condenação do acusado nos termos descritos pela denúncia.

A defesa requer a improcedência da ação penal, com consequente absolvição do réu. É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDIDO.

No mérito, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15); pelo auto de constatação provisória de substância tóxica (fls. 16/17), pelo laudo pericial do local (fls. 58/63); pelos laudos de exame químico-toxicológico (fls. 52/54 e 55/57) e por toda a prova oral colhida em juízo.

O guarda municipal Paulo Eduardo Vedovato disse que estava em patrulhamento e avistou a troca de objetos entre o acusado e terceira pessoa. Localizou dinheiro e oito pinos de cocaína com o acusado e sete pinos de cocaína com Rafael, que lhe disse que estava no local para adquirir entorpecente. Em seguida, o acusado confirmou que estava praticando tráfico no local. Já havia abordado o acusado e nada ilícito encontrado anteriormente. Disse que o acusado estava sempre no local e que se trata de conhecido ponto de venda de drogas.

A guarda municipal Márcia Regina de Souza Pontelli prestou depoimento no mesmo sentido, confirmando que avistou a troca de objetos entre o acusado e Rafael. Disse que seu parceiro localizou R\$ 70,00 em dinheiro e oito pinos de cocaína com o acusado, além de sete pinos de cocaína com Rafael, que confirmou que pagou R\$ 70,00 pelas porções adquiridas.

Em solo policial, Rafael Rodrigues de Oliveira disse que pretendia comprar cocaína para seu consumo pessoal e soube que, no local dos fatos, encontraria traficante. Manteve contato com o acusado, que lhe vendeu sete microtubos contendo cocaína, pagou setenta reais pelas drogas. Logo em seguida, ambos foram abordados por guardas civis (fls. 04).

José Nilton da Silva disse que o acusado trabalhou com o depoente e que ele era bom funcionário

Em solo policial, o acusado Luís Henrique Ferraz de Araújo permaneceu calado (fls. 05).

Em juízo, o acusado disse que os fatos são verdadeiros. Informa que sua família passava necessidade e que já havia praticado tráfico quando ainda menor de dezoito anos. No entanto, em razão da dificuldade financeira, decidiu voltar ao tráfico de drogas. Disse que recebia entre R\$ 60,00 a R\$ 80,00 e que estava praticando tráfico de drogas há dez dias no local.

Com efeito, o depoimento prestado pelos guardas municipais é digno de toda credibilidade, já que devidamente compromissados e inexistentes indícios de interesse dos servidores públicos em prejudicar pessoa inocente. De acordo com a jurisprudência:

PROVA - Depoimento policial - Eficácia - Mera condição de agente público que não torna a testemunha impedida ou suspeita - Precedentes - Recurso improvido.

(Apelação Criminal n. 974.712-3/9-00 - Santos - 14ª Câmara Criminal - Relator: Sérgio Ribas - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 4.191).

PROVA - Depoimento policial - Valor - Credibilidade e responsabilidade equivalentes à palavra dos civis, máxime quando corroboradas pelo conjunto probatório -

Precedentes - Recurso improvido. (Apelação Criminal n. 497.707-3/9-00 - Santos - 5ª Câmara Criminal - Relator: Marcos Zanuzzi - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 13.332).

Aliás, nesse sentido, o próprio acusado disse que nada tem a reclamar a respeito da atuação dos guardas civis municipais, o que confirma que a atuação dos servidores foi correta e o relato por eles prestado merece ser acolhido.

No caso dos autos, as provas carreadas permitem a formação da convicção de que o acusado realmente se dedicava ao tráfico, em razão do relato dos guardas civis municipais no sentido de que viram a movimentação típica do narcotráfico, com troca de objetos entre o acusado e terceira pessoa, inclusive com a apreensão de pinos e dinheiro com o acusado.

Some-se a isso a confissão espontânea do acusado no sentido de que realmente praticava o tráfico de drogas e que havia acabado de vender entorpecentes a Rafael. Bem de ver que o tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06 é misto alternativo, de modo que, comprovado que o acusado trazia consigo quantidade expressiva de droga acondicionada de forma fracionada, deve ser dado como incurso naquele preceito legal. A esse respeito:

“O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente” (RT 776/663). “Ademais, é sabido que o tráfico de entorpecentes é delito de ação múltipla ou conteúdo variado cuja consumação se contenta com a aquisição, transporte, depósito, guarda ou simples porte da droga, desde que não seja para consumo pessoal. Daí não haver falar em mero auxílio ao uso de drogas, visto que a paciente foi flagrada na posse de maconha e cocaína. (STJ, HC 211.467/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, 6ª TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 31/08/2011).

Nem se diga que o acusado enfrentava dificuldade financeira, pois não há prova nesse sentido, apenas o relato do acusado, anotando-se que a testemunha de defesa apenas asseverou que está disposta a contratar o acusado quando ele for beneficiado com a liberdade.

Inviável a desclassificação para a figura do artigo 28 da lei n. 11.343/06, na medida em que o acusado vendeu as 7 porções de cocaína a terceira pessoa e confirmou que estava naquele ponto para vender drogas, o que indica que o pedido defensivo não encontra respaldo na prova produzida.

Passo à dosagem da pena, em conformidade com o disposto nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Em primeira fase, favoráveis as circunstâncias judiciais, fixo a pena privativa de liberdade em seu patamar mínimo, isto é, em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Em segunda fase, ausentes agravantes, mas estão presentes as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, sem reflexo sobre a pena aplicada, pois já estipulada no mínimo legal (súmula 231 do STJ).

Em terceira fase, incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da lei n. 11.343/06, já que o laudo pericial (fls. 58/63) revela que nas imediações do local onde os fatos ocorreram existem estabelecimento de ensino, praça pública e unidade básica de saúde, o que evidentemente facilita a propagação do tráfico de drogas devido ao maior fluxo de pessoas.

Aliás, a lei não exige que aqueles sejam os locais especialmente visados pelo infrator, bastando a proximidade física. A esse respeito:

A traficância era exercida em local inequivocamente próximo das escolas “Zumira” e “Rubens Leme Asprino” (distava aproximadamente 800 metros da primeira e 490 metros da segunda - vide fls. 74/7), sendo que para a incidência da majorante referente ao artigo 40, inciso III, não exige a lei que o estabelecimento de ensino seja especialmente visado pelo infrator, bastando, tão somente, a proximidade física e o conhecimento dessa proximidade. (TJSP, Apelação n. 0004114-44.2011.8.26.0083, Relator Des. Geraldo Wohlers, julgado aos 26.2.2013, 3ª Câmara de Direito Criminal) Ainda sobre essa questão, o Col. Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se pronunciar no sentido de que “(...) O tráfico de drogas nas imediações de estabelecimentos de ensino é suficiente para incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, independente de os agentes visarem ou não os frequentadores daquele local (...). Destarte, não procede a alegação da impetrante no sentido de que não há demonstrativo de relação evidente entre a conduta dos pacientes e as atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos ensino, uma vez que é irrelevante o fato de haver ou não intenção dos acusados de atingir os frequentadores do estabelecimento. Para incidência da mencionada causa de aumento de pena, basta a proximidade física do local onde o tráfico estava sendo praticado e o estabelecimento de ensino, o que ficou corretamente assentado pelas instâncias ordinárias.” (HC 116.929/SP, 1ª Turma, relator Min. Luiz Fux, julgado aos 15.10.2013).

No mesmo sentido, posiciona-se o E. Superior Tribunal de Justiça, que em precedente desta Comarca decidiu que: No entanto, o Superior Tribunal de Justiça possuía entendimento no sentido de ser desnecessária, para a incidência da majorante do artigo 40, III, da lei de drogas, a comprovação de que o comércio de ilícito de substâncias entorpecentes vise atingir os alunos do estabelecimento, bastando, para

sua incidência, que a prática da traficância tenha ocorrido nas imediações da escola (RESP n. 1.774.414/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 22.2.2019).

Nem se diga que os fatos não ocorreram nas imediações de estabelecimento de ensino, ou que o fato teria ocorrido em data em que não havia expediente escolar, o que não justificaria a incidência da causa de aumento.

Isso porque a denúncia descreve que, além da escola, o fato foi praticado nas imediações de unidade básica de saúde situada a 192 metros de distância, o que confirma a possibilidade de maior afluxo de pessoas pela imediação e justifica, assim, a incidência da causa de aumento.

Por estes fundamentos, majoro a pena em 1/6, resultando pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias multa.

Ainda em terceira fase, não incide a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da lei n. 11.343/06, porque o acusado ostenta anterior execução de medida socioeducativa (fls. 28 e 87/91 e 92/97) e permaneceu custodiado na fundação CASA pela prática de fato análogo ao tráfico de drogas (fls. 97). A esse respeito:

Ainda nessa etapa, no meu ponto de vista, realmente não é caso de se aplicar o redutor do § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas ao apelante, já que compartilho do entendimento do Juiz sentenciante no sentido de que ficou demonstrado que ele se dedicava a atividades criminosas, em razão de ter admitido que vendia drogas há uma semana, além de já possuir um registro por ato infracional perpetrado quando adolescente, equiparado ao tráfico (TJSP, Autos n. 007605-85.2017, Relator Des. Nelson Fonseca Júnior, 10ª Câmara de Direito Criminal, julgado aos 23/8/2018).

“[a] existência de atos infracionais praticados pelo agente, embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem denotar dedicação às atividades criminosas, de modo a justificar a negativa da minorante do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ante o não preenchimento dos requisitos legais” (STJ, AgRg no REsp nº 1.560.667- SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. em 17.10.2017, DJe 23.10.2017).

Como já dito, ostentando envolvimento em atividades criminosas, o agente não faz jus ao benefício destinado a iniciantes na seara delitiva, razão pela qual fica afastada a aplicação da minorante mencionada.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal.

De acordo com o total de pena imposta e porque favoráveis as circunstâncias judiciais, o regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto. Nesse sentir:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS.

APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.

IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO

MANDAMUS. REGIME FECHADO COM BASE NA HEDIONDEZ DO DELITO. DESCABIMENTO. REGIME

SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 44, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE

NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL

DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental

deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente

firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios

fundamentos. II - In casu, v. acórdão impugnado fundamentou o afastamento do

tráfico privilegiado, consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava a atividades criminosas (traficância), em razão não somente pela quantidade de drogas

apreendidas, mas também pelas circunstâncias em que se deu a prisão, bem como

constatarem que não se tratava de traficante ocasional. Tudo isso, são elementos

aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial

de diminuição, como reclama a impetrante, demandaria, necessariamente, amplo

revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é

incompatível com a estreita via do mandamus. III - Considerada a quantidade de pena

aplicada (5 anos de reclusão), bem como fixada a pena-base no mínimo legal, em

virtude da análise favorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código

Penal, constata-se a existência de constrangimento ilegal decorrente da imposição

do regime fechado, de sorte que o paciente faz jus ao regime inicial semiaberto, o

qual se revela como o mais adequado à prevenção e à repressão do delito em tela,

conforme o art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. IV - Mantida a pena cominada ao paciente em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, resta prejudicado o pedido de substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos, pois não preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 44 do Código Penal. Agravo regimental desprovido.

(....)

No tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, insta consignar que o Pleno do eg. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 111.840/ES, por maioria de votos, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, com a nova redação dada pela Lei n. 11.464/2007, por ofender a garantia constitucional de individualização da pena (art. 5º, XLVI, da Constituição Federal). Afastou, dessa forma, a obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado para os condenados pela prática de crimes hediondos e dos demais delitos a eles equiparados. Em tal contexto, nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o Julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e, em se tratando dos crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, como no caso, deverá levar em conta a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). Na hipótese, verifica-se nos excertos acima colacionados que o v. acórdão impugnado manteve o regime prisional fechado, amparando-se tão somente na hediondez do delito (tráfico de drogas), sem indicar elementos concretos dos autos que demonstrassem a real necessidade de imposição de regime prisional mais gravoso, o que vai de encontro ao teor dos Enunciados ns. 718 e 719 da Súmula do STF, bem como do Enunciado n. 440 da Súmula do STJ, que assim dispõem:

(....)

Sob essa perspectiva, considerada a quantidade de pena aplicada (5 anos de reclusão), bem como fixada a pena-base no mínimo legal, em virtude da análise favorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, constata-se a existência de constrangimento ilegal decorrente da imposição do regime fechado, de sorte que o paciente faz jus ao regime inicial semiaberto, o qual se revela como o mais adequado à prevenção e à repressão do delito em tela, conforme o art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. (Superior Tribunal de Justiça, AgRg no HABEAS CORPUS Nº 604.250 - SP, julgado aos 6/10/2020, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma) Inviável a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do total da pena imposta.

Por estas razões, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO Luís Henrique Ferraz de Araújo à pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 583 dias-multa, cada qual no mínimo legal, dando-o como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06.

O réu respondeu ao processo no cárcere e com a condenação ficam reforçados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, razão pela qual lhes nego o direito de recorrer em liberdade, anotando, ainda, que o crime de tráfico de droga atenta contra a ordem pública, fustigada pelo avassalador crescimento dessa prática espúria, bem como porque o acusado ostenta vasto histórico de envolvimento em atos infracionais, o que indica que sua liberdade configura risco concreto à ordem pública.

A esse respeito, já decidiu o C. STJ que: "Embora o registro de ato infracional não possa ser utilizado para fins de reincidência ou maus antecedentes, por não serem considerados crimes, podem ser sopesados na análise da personalidade do recorrente, reforçando os elementos já suficientes dos autos que o apontam como pessoa perigosa e cuja segregação é necessária. Precedentes." (5ª Turma - HC 466.866/PE, j. 02/10/2018). Recomende-se na prisão, com expedição de ofício.

Decreto o perdimento do numerário apreendido, pois se trata de produto do tráfico de drogas. Oficie-se após o trânsito em julgado.

Expeça-se certidão de honorários ao defensor dativo.

Custas ex lege, observada eventual gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

PRI.

Mogi Guacu, 17 de março de 2022.

Paulo Rogério Malvezzi

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA